

1500791-13.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... pena superior a que seria cabível se se tratasse aqui de tráfico de poucas quantidades de droga e de menor potencialidade lesiva. Por tais razões, merece uma reprimenda maior do Estado, conforme têm decidido nossos Tribunais Superiores, fazendo alusão ao princípio da proporcionalidade: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500791-13.2021.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500791-13.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2277293/2021 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 20757940 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 1389/21/925 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 2277293 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 1389/21/925 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 147/2021 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK MARQUES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

.

Vistos,

ERICK MARQUES DA SILVA, qualificado a fls.14, está sendo denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 09 de outubro de 2021, por volta de 19h20, na Rua do Cromo, nº 259, na Vila Mollon, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, guardava e ocultava, para fins de entrega a consumo de terceiros, cerca de 725,0g de cocaína divididas em três formas diferentes, quais sejam, ½ tijolo, 01

uma porção menor e 186 papelotes (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 11/13 e auto de constatação preliminar de substâncias entorpecentes a fls. 16/17), fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo foi apurado, o denunciado obteve, por meios ainda não esclarecidos, a posse das drogas descritas acima para fins de guarda e, posterior, entrega a consumo de terceiros.

Ocorreu que, guardas municipais estavam em patrulhamento pela Vila Mollon, quando avistaram ERICK saindo de um imóvel e, como ele já era conhecido em razão de denúncias de estar em pontos de venda de drogas, decidiram abordá-lo.

Realizada a abordagem e a revista pessoal, em poder de ERICK foi encontrada a quantia de R\$ 224,00. Durante a abordagem, depois de mentir dizendo que residia em Americana, acabou apontado que residia na Rua do Cromo, nº259, Mollon, nesta cidade de Santa Bárbara D'Oeste.

Questionado pelos guardas, o denunciado admitiu que realizava a guarda de certa quantia de cocaína em sua casa e que a droga se destinava à venda. Por esse motivo, os guardas se dirigiram ao endereço indicado, onde foram recebidos por Fernanda Carolina, companheira do denunciado, que lhes franqueou a entrada ao imóvel.

Em seguida, ERICK indicou que as drogas estavam dentro do quarto da filha, sendo então localizado meio tijolo de cocaína sobre o guarda-roupas.

Em buscas pelo imóvel, na área de serviço, foi encontrada uma mochila, dentro da qual foram encontradas 186 porções de cocaína embaladas individualmente e prontas para a venda, além de uma outra porção maior de cocaína. Dentro da mochila havia ainda 02 balanças de precisão, 18 pacotes de saquinhos plásticos nas cores azul, rosa e transparente, 02 colheres/medidores de plástico, 05 colheres, 02 facas, 01 tesoura, 01 bolsinha plástica.

Numa sapateira existente na sala, foi encontrada a quantia de R\$ 1.000,00 em espécie, cuja origem lícita não foi comprovada até o momento.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o autuado confessou o tráfico afirmando que recebeu o entorpecente de um conhecido para guardá-lo por uma semana em troca da quantia de R\$ 300,00 (fls. 22/23).

Portanto, as circunstâncias da apreensão das drogas, a elevada quantidade, bem como o encontro de dinheiro e dos objetos comumente utilizados para fracionamento, armazenamento e embalo de drogas, aliados aos relatos dos guardas municipais evidenciam que as substâncias entorpecentes pertenciam ao denunciado e que se destinavam a entrega a consumo de terceiros.

O réu foi notificado (fls.106) e apresentou defesa preliminar (fls.99/102). A denúncia foi recebida em 16 de Novembro de 2021 (fls. 117/119). E o réu foi citado (fls.186). Durante a instrução processual foram ouvidas três testemunhas em comum, interrogado o acusado ao final.

Em suas alegações finais, pede o Ministério Público a procedência do pedido, nos termos da denúncia, face a comprovação da autoria e materialidade delitivas. A defesa, por seu turno, pugna pela nulidade processual, face a ação dos guardas municipais, com a consequente absolvição por falta de provas; em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, com regime mais brando, e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

De início, afasto a alegação de nulidade decorrente de eventual ilegalidade da prova obtida, seja pela alegada ausência de mandado judicial ou pelo fato de não ter sido autorizada a entrada dos guardas municipais, pois não se verifica afronta ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Isso porque, os guardas municipais já tinham informação a respeito do envolvimento do acusado no tráfico de drogas, e ao abordá-lo em via pública, ele acabou confessou que havia entorpecente em sua casa, autorizando o ingresso destes agentes.

Nota-se que nada há nos autos a revelar que houve ingresso forçado destes agentes no domicílio do réu; a esposa do acusado, que também consentiu com este ingresso, segundo os guardas municipais, não foi ouvida em audiência para firmar o contrário, havendo desistência da defesa em sua oitiva.

No mais, "a conduta daquele que tem em depósito substância entorpecente sem autorização legal caracteriza estado de flagrância, o que afasta a exigência de mandado judicial, conforme exceção do art. 5º, XI, da Constituição Federal." Habeas corpus indeferido. (HC 74963, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 25/03/1997, DJ 09-05-1997 PP-18131 EMENT VOL-01868-03 PP-00568).

A inviolabilidade do domicílio é assegurada na Constituição Federal, mas encontra limites no mesmo texto constitucional, incluindo-se no rol das escassas hipóteses de mitigação deste direito fundamental a possibilidade de ingresso em domicílio sem mandado judicial nos casos de flagrante delito, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República.

In casu, o crime de tráfico de drogas configura crime permanente e sujeita o autor da conduta ao estado de flagrância enquanto perdurar a prática criminosa, prescindindo-se, portanto, de mandado de busca e apreensão durante a ocorrência do delito.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico da jurisprudência:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO DA DROGA. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DO REFERIDO LAUDO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS (MACONHA E CRACK). PRISÃO ANTERIOR PELO MESMO DELITO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. O tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua residência, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito, sendo, portanto, absolutamente legítima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente, portanto, de mandado judicial. [...] Habeas Corpus não conhecido. (HC 307.156/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 09/06/2015).

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE QUE CARACTERIZA ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem da ordem de

ofício. II - Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (precedentes). III - Ademais, a defesa, em sua apelação, somente suscitou a nulidade da ação policial que teria sido conduzida em razão de denúncia anônima. Por outro lado, in casu, houve contato policial com informantes (usuários de drogas), a indicar a fundada justificativa da medida de busca e apreensão. Habeas corpus não conhecido" (HC 345.424/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 16/09/2016).

Assim, não há que se falar em violação de domicílio e na consequente nulidade das provas que advieram do ato, pelo que rejeito a alegação preliminar.

Passo à análise do mérito.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende pelo Boletim de Ocorrência de fls.7/10, auto de exibição e apreensão de fls.11/13, auto de constatação preliminar de fls. 16/17, laudo de entorpecentes fls.108/110 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também é certa.

Os guardas municipais Jairo José dos Santos e Alberto Firmino dos Santos deram versões essencialmente iguais. Disseram que já tinham informações do acusado Erick, apontando como gerente da biqueira na rua Mercúrio, bairro Mollon, e que ele era o responsável por distribuir droga. Que ele já foi abordado neste local, e sempre dizia que morava em Americana. No dia dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro, e viram Erick sair de uma residência. Ele foi abordado e com ele foi encontrada a quantia de R\$ 224,00. Indagado, disse novamente que morava em Americana e estava voltando de um bar, mas disseram que o viram sair da residência, então ele ficou nervoso e acabou confessando que morava naquela casa. Que foi dito a ele a respeito da denúncia de tráfico de drogas, e ele acabou confessando que estava embalando drogas na sua residência. Que com a autorização dele entraram na casa, e ele apontou o armário dentro do quarto do bebê, e então foi encontrado um tijolo de cocaína. Foi indagado a respeito de mais drogas, ele negou, mas em revista pessoal, na área de serviço, embaixo de roupas sujas, foram encontradas uma porção menor de cocaína, e mais 186 porções embaladas. Também havia uma mochila contendo peneira, balança, colher, faca, sacos plásticos sujos de droga, tesoura, e vários sacos plásticos espalhados pela casa, também sujos de droga. O acusado disse que estava embalando drogas e uma pessoa passaria para pegar as porções embaladas e levar para serem vendidas. A casa estava bem bagunçada, exalava odor de fezes de cachorro, e não sentiram cheiro de cocaína. Que a esposa acompanhou as buscas e dizia que não sabia de nada. Que no móvel da cozinha foi encontrada a quantia de R\$ 1.000,00. Que foram apreendidos celulares da esposa e do acusado.

O acusado, em seu interrogatório, confessou parcialmente os fatos. Disse que naquele dia saiu de casa para cortar o cabelo e foi abordado pelos guardas municipais. Que estava com R\$ 224,00 em dinheiro e o celular. Eles indagaram a respeito de drogas, e negou. Que os guardas entraram na sua casa, sem autorização, e de pronto entregou a mochila para eles que estava em cima do guarda roupa, onde estava todo o entorpecente e os materiais para embalo. Que não mexeu naquela droga, e estava guardando para pagar uma dívida de droga, pois em outra oportunidade tinha guardado droga no mato, e perdeu, então ficou devendo R\$ 500,00 para o traficante. Que ia receber R\$ 800,00 pela guarda do entorpecente, e os trezentos reais ia pagar contas. Fazia um mês que a droga estava na sua casa. Que morava de aluguel há um mês e estava desempregado. Não consegue emprego. Estou até o segundo colegial. Trabalhou na empresa Multifitas e foi mandado embora. Que a esposa não sabia de

nada. É usuário de maconha e cocaína. Tem 23 anos e a família mora em Americana. Não é a primeira vez que guardou drogas. Já foi preso num furto. Não conhece os guardas municipais.

Em que pese a alegação do acusado, estou convencida de que os fatos se deram na forma como apresentada pelos guardas municipais, pois os relatos são uníssonos, coerentes, seguros e isentos, não se observando, em nenhum momento, que eles inventarem uma história apenas com o objetivo de prejudicá-lo.

Nada há nos autos apontando que eles ingressaram na residência sem autorização, bem assim que havia apenas uma mochila guardada no armário, com as porções da droga e os materiais de embalo, na forma como descrita pelo acusado. Quer ele fazer crer que apenas guardou drogas para pagar dívida (como se esta conduta não se adequasse perfeitamente ao tipo penal), e não tinha nenhum envolvimento com o comércio deletério, mas os agentes foram firmes em afirmar que havia vários resquícios de manipulação daquela droga, com saquinhos sujos de droga espalhados pela casa, além de faca, tesoura suja, além da própria droga estar espalhada pela casa. Até no quarto do bebê havia um tijolo grande, conforme informaram os guardas municipais, revelando a desfaçatez do acusado nesta prática delitativa.

No mais, presume-se que os agentes municipais sejam homens sérios, dedicados e fiéis cumpridores da lei, dedicados ao difícil ofício de contribuir no combate à criminalidade local. Para contrapor tal presunção, não bastam meras alegações infundadas; necessário prova concreta e robusta da injustiça da prisão, ou mesmo elementos suficientes que pudessem causar a dúvida no julgador, o que sequer existe nestes autos, pois nenhuma prova foi produzida para amparar a narrativa do acusado, restando seu depoimento totalmente isolado do restante probatório.

Neste cenário, com tranquilidade reconheço a validade e a importância dos depoimentos dos guardas municipais para fundamentar a condenação criminal, pois inexistem elementos para considerá-los indignos.

Nesse sentido, a jurisprudência é farta:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF, HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello).

“PROVA - Testemunha - Crime de tráfico de entorpecentes - Depoimento prestado por policiais - Validade - Presunção de que, no desempenho de suas funções, agem escorreitamente - A circunstância de ser policial a testemunha não afeta (positiva ou negativamente) o valor probante de sua palavra - Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição - Afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade, segundo os critérios ordinariamente aplicados - Recurso parcialmente provido”. (TJSP, Ap. n. 993.07.105623-5 - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Souza Nery - 06.08.08 - V.U).

“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam declarações como testemunhas em processo criminal, posto que ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado principalmente quando em

harmonia com o conjunto probatório colecionado -Recurso defensivo não provido.
(TJSP, Ap.n. 0000179-16.2010.8.26.0411 - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Camilo Léllis dos Santos Almeida - 05/06/2014).

"TJSP. Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/275).

Sendo assim, diante do conjunto probatório coerente e robusto, formado pelas circunstâncias de armazenamento da droga, da quantidade elevada, ou seja, ½ tijolo, 01 porção menor e 186 papelotes de cocaína, totalizando 725 gramas, além dos materiais destinados ao embalho, como 02 balanças de precisão, 18 pacotes de saquinhos plásticos, 02 medidores, 05 colheres, 02 facas, 01 tesoura e uma bolsa plástica, além do numerário cuja origem lícita não foi comprovada, entendo bem comprovada a prática do crime de tráfico de drogas pelo réu. A condenação é medida que se impõe.

Passo, então, a dosar a pena.

Primeira fase: Primeira fase: Primeira fase. Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é reincidente (fls. 36/37), o que será usado na segunda fase de aplicação da pena. Ademais, o artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente", e neste caso em concreto, o acusado comercializava elevada quantidade de droga: cerca de 725,0g de cocaína divididas em três formas diferentes, quais sejam, ½ tijolo, 01 uma porção menor e 186 papelotes. A natureza nefasta do entorpecente - cocaína - também vem em seu desfavor, diante do grande potencial devastador, bem superior a outros tipos de entorpecente, e que tem contribuído para a destruição de famílias e aumento da criminalidade. É forçoso concluir, assim, que a conduta praticada pelo acusado afetou de modo especialmente grave a saúde pública, o bem jurídico tutelado pelos tipos penais da Lei 11.34/2006, o que, por si só deve ensejar a imposição de pena superior a que seria cabível se se tratasse aqui de tráfico de poucas quantidades de droga e de menor potencialidade lesiva. Por tais razões, merece uma reprimenda maior do Estado, conforme têm decidido nossos Tribunais Superiores, fazendo alusão ao princípio da proporcionalidade: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido." (AgRg no REsp 1793804/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). Considerando, assim, tais circunstâncias - quantidade elevada e natureza do entorpecente - aumento a pena base de 1/3 (1/6 para cada circunstância desfavorável), totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal. Segunda fase: a atenuante da confissão não será considerada, pois foi apenas parcial, posto que o acusado confessou a posse do entorpecente, mas negou o comércio e imputou aos agentes municipais conduta abusiva e arbitrária, buscando, com isso, invocar nulidade processual e afastar sua responsabilidade penal, distorcendo, assim, a verdade dos fatos. Desse modo, não pode ser ele beneficiado com a redução da reprimenda. Nesse sentido o posicionamento da jurisprudência: "A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexistente

verdade total da dinâmica da ocorrência penal " (TACRSP, RJDTACRIM 31/84). E mais: " Em se tratando da atenuante da confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não pode reclamar a obtenção do valor legal, pois, além do requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de penas, confissão pela metade " (TACRSP, RJDTACRIM 33/56). Presente a agravante da reincidência (Processo nº 0000236-12.2017 fls.36/37), o que justifica o aumento da pena de mais 1/6, resultando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias multa. Terceira fase: Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, esclarecendo que diante da reincidência do acusado, fica vedada a diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Tóxico. E ainda que assim não fosse, tem-se que o acusado vinha se dedicando às atividades criminosas (declarou não ser a primeira vez que guardou drogas), e tinha plena consciência de estar contribuindo efetivamente para organização voltada para o tráfico de entorpecente, sobretudo diante da elevada quantidade de drogas apreendidas em seu poder. Ora, só quem goza de confiança dos demais membros da organização tem a tarefa de guardar e embalar tamanha quantidade de drogas em casa, até mesmo porque sabe-se do valor econômico deste material. Não seria destinada esta função para o iniciante, o desconhecido, aquele que não tem nenhum conhecimento da vida do tráfico, o que revela que ele estava integrado neste ambiente odioso. Comentando o § 4º do artigo 33, os autores Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na obra "Lei de Drogas Comentada", ed. Método, 1ª edição, p. 98, explicam que "o intuito da lei é somente beneficiar o 'pequeno traficante', que não possui conduta voltada para o crime e que não esteja envolvido 'definitivamente' com o tráfico". Restando inaplicado o redutor, fica fixada, em definitivo, a pena em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 777 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.

Não há que se falar em bis in idem na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, aplicável apenas ao réu primário e de bons antecedentes, conforme entendimento pacificado no E. STJ:

A propósito, confirmam-se os seguintes precedentes:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART.33, 4º, DA LEI 11.343/06. PRETENDIDO RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. BIS IN IDEM. NAOCONFIGURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NAO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, necessário o preenchimento de todas as condições elencadas na lei, quais sejam, além da primariedade, a ausência de antecedentes desabonadores, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 2. Inviável o reconhecimento da minorante em questão quando evidenciado que o paciente é comprovadamente reincidente, pouco importando se a reincidência é específica ou não, já que ausente qualquer distinção feita pelo legislador nesse sentido. 3. Não há que se falar em bis in idem quando considerada a reincidência na segunda etapa da dosimetria, como agravante genérica, e na terceira fase de aplicação da pena, como impeditivo para o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, 4º, da Lei n.º 11.343/06, pois se trata apenas de um mesmo parâmetro de referência para momentos e finalidades distintas, objetivando a aplicação da reprimenda proporcionalmente suficiente à prevenção e à reprovação do delito, nas circunstâncias em que cometido. 4. Ordem denegada." (HC 178.933/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 09/03/2011.).

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33,4º, DA LEI N.º 11.343/2006. NAO PREENCHIMENTO DE UM DOS SEUS REQUISITOS. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. I - Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois expressamente reconhecido na

r. sentença condenatória que o paciente, por ser reincidente, não preenche os requisitos legais. II - Dentro dos limites legais, uma vez configurada a reincidência, a agravante deve ser aplicada. III - Não resta caracterizado bis in idem na utilização da reincidência como causa ensejadora da não aplicação da minorante do art.33, 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como agravante da pena, ante expressa previsão legal. Habeas corpus denegado." (HC 148.575/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 04/10/2010.)

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/90, com a redação nova que lhe foi dada pela Lei 11.464/07, além de ser o réu reincidente, na forma do artigo 33, §2º alínea "a" do CP, denotando sua personalidade voltada ao crime, o que exige a imposição do regime mais gravoso para efetiva prevenção e reparação do delito.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos por ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal- quantidade elevada de pena e a reincidência - bem como diante da expressa proibição legal prevista no artigo 44 da Lei 11.343/06.

Nego o direito ao acusado de apelar em liberdade, pois presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP. A elevada quantidade de pena aplicada e o regime prisional mais gravoso exige o encarceramento para garantia da aplicação da lei penal. Não há nos autos prova de que o acusado exerça ocupação lícita, ao contrário, declarou ser dedicado ao vício em entorpecente. Nada impede, assim, que fuja do distrito da culpa para furtar-se ao cumprimento desta pena. Também há necessidade de garantir a ordem pública. O acusado é reincidente, o que indica sua personalidade desvirtuada e voltada ao crime. Solto, com sensação de impunidade e com esta conduta social reprovável, decorrente da contumácia em prática delitivas, certamente voltará a delinquir. Necessário, assim, extirpar do seio da sociedade pessoas que conturbam a ordem pública. O Judiciário não pode se furtar à efetiva reprimenda do crime de tráfico de drogas, cujos efeitos são graves e nefastos, pois não só fomenta a prática de outros crimes, geralmente furtos e roubos por parte dos usuários, que tentam manter o vício, mas também porque seus agentes são verdadeiros causadores da destruição de vidas e famílias.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar o réu ERICK MARQUES DA SILVA, qualificado a fls. 14, às penas 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal., com incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se na que se encontra.

Se o caso, expeça(m)-se a(s) certidão(ões) de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as providências: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu; d) proceda-se à incineração da droga apreendida, nos termos do parágrafo 1º do art. 32 Lei de Tóxicos; e) expeça-se guia de execução penal.

Declaro o perdimento do numerário apreendido (fls. 12) em favor da FUNAD, pois proveito do crime. Já os celulares apreendidos, autorizo a devolução ao legítimo proprietário, desde que comprovada nos autos a efetiva propriedade. Caso o

interessado não compareça nos autos em até cinco dias após o trânsito em julgado, autorizo a destruição.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA